

1500194-95.2022.8.26.0246

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Luis Monteiro Piassi

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... exige para a configuração do crime de tráfico a presença de elemento subjetivo especial do tipo, como o faz para o delito de posse de droga para consumo próprio. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, em seu Legislação Criminal Especial Comentada (2021, p. 1.068):

"Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

2ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500194-95.2022.8.26.0246 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500194-95.2022.8.26.0246

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086011/2022 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 23935369 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2086011 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THÁYRA GABRIELA ALVES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

I - RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra a Sra. Tháyra Gabriela Alves da Silva.

Na denúncia, narra-se que no dia 29 de março de 2022, por volta das 08h01min, na residência situada no Passeio Sobral, nº 206, Zona Norte, em Ilha Solteira/SP, Tháyra Gabriela Alves Silva, ouvida e qualificada às fls. 13, guardou e expôs à venda, sem autorização legal e regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 0,13 gramas, e 04 (quatro) pedras de substância entorpecente popularmente conhecida como crack, derivada da cocaína, com peso bruto aproximado de 0,13 gramas, de acordo com auto de exibição e apreensão de fls. 30/32, auto de constatação preliminar de fls. 33/34, laudos de exames toxicológicos de fls. 91/93 e 143/145 e fotos de fls. 42/51 e 57.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 79/81).

Os laudos de constatação provisória (fls. 33/34) e definitiva tiveram resultado positivo para "cocaína e maconha" (fls. 91/93 e 143/145).

Perícia realizada nos aparelhos celulares da ré (fls. 150/153)

Notificada pessoalmente (fl. 189), aré ofereceu defesa escrita (fls. 221/224).

Recebida a denúncia em 08 de julho de 2022.

No curso da instrução (fls. 260), realizou-se oitiva em audiência de 3 testemunhas arroladas em comum, 2 testemunhas da defesa e da ré.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a defesa pediu a absolvição, ante a falta de provas da autoria.

Folha de Antecedentes Penais (fl. 233/234) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fl. 235/236).

É o relatório.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da Imputação dos Crimes praticados pela Sra. Tháyra Gabriela Alves Silva.

Na inicial, é imputado ao acusado a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 núcleos, tratando-se de tipo misto alternativo, ou seja, ainda que o agente pratique mais de um núcleo, a ele será imputado apenas um delito. Além disso, da leitura do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conclui-se que o crime pode restar configurado ainda que a alienação da droga se dê gratuitamente, mas desde que a conduta seja praticada sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ato contínuo de análise do tipo penal, deve-se observar que a lei não exige para a configuração do crime de tráfico a presença de elemento subjetivo especial do tipo, como o faz para o delito de posse de droga para consumo próprio. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, em sua Legislação Criminal Especial Comentada (2021, p. 1.068):

“Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (Dezoito) verbos constantes do art. 33. A propósito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm precedentes no sentido de que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo – o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir).”

No sentido que se vem de expor, veja-se o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça

fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

As substâncias apreendidas foram identificadas pelos peritos como tetraidrocanabinol e cocaína, definidas como droga pelo art. 66 da Lei nº 11.343/2006 e pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

O auto de apreensão (fls. 30/32) e a prova oral produzida em juízo provam que estavam na posse da ré.

Em juízo, a testemunha comum Eduardo Martins, Policial Civil, declarou que: as investigações se iniciaram devido a uma denúncia. Em diligências, constataram grande movimentação de pessoas em duas residências, sendo uma delas de propriedade da ré. No cumprimento do mandado de prisão, encontraram entorpecentes, dinheiro e celulares na residência da acusada. O menor, David, tinha relacionamento amoroso com a ré e pernoitava no local. Havia grande movimentação de pessoas no imóvel. Na entrada do imóvel (garagem), havia uma Qrcode para pagamento via PIX. Indagada, a ré disse desconhecer alegando que quando se mudou já estava no local. Entretanto, em diligências conseguiram identificar que o Qrcode correspondia a conta bancária da ré. Posteriormente, a acusada disse que promovia a venda de semi-joias. As drogas estavam distribuídas pelo quarto e cozinha. Argumentou que as pessoas que adentravam ao imóvel tinham comportamento de usuários de entorpecentes.

A testemunha comum Marcos Ferreira Cristofoli, Guarda Municipal, declarou que: participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Durante a ocorrência, encontraram a ré e o adolescente em um quarto. No cômodo, encontraram uma porção de crack e dinheiro. Em revista pelo imóvel e, com o auxílio do cão farejador, encontraram mais porções de drogas em outros cômodos do imóvel, bem como celulares e papel filme com resquícios de drogas. Reitera que não tem conhecimento das investigações.

A testemunha de defesa David Venancio Moreno dos Santos, ouvido como informante por ter declarado que se relaciona amorosamente com a acusada, declarou que: há época dos fatos estava "ficando" com a ré, há aproximadamente 10 dias. Asseverou que a acusada não tinha conhecimento de seu envolvimento com o tráfico. Assumiu a titularidade dos entorpecentes e dos petrechos encontrados. Levou entorpecente ao imóvel dois dias antes da abordagem. No dia dos fatos fez venda de entorpecentes. Durante os 10 dias anteriores ao ocorrido, foi à residência da ré todos os dias. Confirmou a propriedade da balança, alegando que a utilizava para controlar seu uso

de drogas. Argumentou que a ré não tinha conhecimento das porções de drogas. Não havia grande circulação de pessoas no local.

A testemunha de defesa Taina Rodrigues da Costa, declarou que: alugou um quarto na residência da acusada. Na noite anterior aos fatos, dormiu no local. Não avistou o adolescente na residência no dia anterior. Nega que havia grande movimentação de pessoas no imóvel. Argumentou que a acusada lhe disse que: “não ia mais mexer com isso, pois estava arrependida”. Trabalha no município de Selvíria pela manhã (das 6 às 12 horas), retornando à Ilha Solteira para trabalhar como babá (das 13 às 21:30 horas). Permanecia na residência no período compreendido entre: 21:30 horas às 6 horas do dia seguinte. Disse que conversavam com a ré durante o período noturno e que não havia outra pessoa que visitasse o local. Passou a residir no imóvel da ré no mês de abril ou maio, porém, posteriormente disse que não se recordava da data. Não sabe quando se deu a primeira prisão da ré, dizendo apenas que se deu em momento anterior a sua chegada ao imóvel.

A acusada Thayra Gabriela Alves Silva, declarou que: no dia dos fatos estava dormindo com o adolescente quando foi surpreendida pelos agentes. Disse que foi retirada para fora do imóvel, enquanto o adolescente permaneceu na parte interna com os agentes policiais. Nega os fatos e a propriedade da droga. Estava se relacionando amorosamente com o adolescente, porém não tinha conhecimento do seu envolvimento com drogas. Não sabia que o menor fazia uso e/ou guardava drogas em sua casa. O adolescente só acessava o imóvel com sua autorização, porém, já deixou as chaves da residência com ele. Nega que houvesse tráfico de drogas no local. Pois bem.

O policial civil, o Sr. Eduardo Martins, que conduziu as investigações que levaram à prisão da ré, foi enfático ao afirmar que a ré estava envolvida com o comércio de drogas.

Pese o informante, o Sr. D.V.M.D.S ter assumido a posse das drogas para uso e traficância, tenho que sua palavra deve ser acolhida com parcimônia, diante da alegada relação de afeto existente entre ele e a ré.

Neste ponto, não é crível a negativa da ré no sentido de que não teria visto as drogas no criado-mudo que guarnecia o quarto conjugal, conforme relatado à fl. 162.

A testemunha, a Sra. Tainá disse que não morava com a ré quando de sua primeira prisão em flagrante; quando da segunda, estava morando com ela, e, segundo seu relato, a ré dizia ter se assustado com o que acontecera e que não voltaria a traficar. Todavia, certo é que a testemunha passava larga parte de seu dia fora da residência, entre as 6 e as 21hs, donde a impossibilidade de ter ciência do que ocorria na casa.

O(s) acusado(s), apesar de negar(em) os fatos descritos na denúncia, não deu(ram) qualquer explicação plausível e convincente para os fatos retratados nos autos nem trouxe qualquer prova que pudesse confirmar e subsidiar sua versão, sendo que chegou a sugerir que as drogas foram implantadas no local.

As declarações do(s) réu(s) não demonstram coerência com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. A versão por ele(s) apresentada não guarda correspondência com a realidade, porque a narrativa empregada é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal. Os argumentos, portanto, mostram-se inverossímeis, por não encontrar respaldo fático.

Percebe-se, enfim, no(s) discurso(s), o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita.

Desta feita, reputo que os entorpecentes estavam na posse da parte ré.

Assim, a prova produzida ao longo da instrução criminal, não dá margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, porque angariada com elementos seguros. Não se viu nenhum indício de que evidencie a insinceridade, justifica sua recusa, pelo contrário, representa dados relevantíssimos na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

No caso, a quantidade e diversidade de droga apreendida, as circunstâncias da

apreensão, a localização de dinheiro desprovido de comprovação de sua origem, bem como a apreensão de balança de precisão demonstram que era destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico.

No caso, há elementos seguros que demonstram que era destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico e não o de posse de drogas para consumo, razão pela qual afastado o pedido desclassificatório. Anoto ser ponto pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido (HC 461377/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; EDcl no HC 463656/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 24/10/2018).

Por todos, veja-se o seguinte precedente do STF:

"HABEAS CORPUS - CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do cabimento e processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS - CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS - INSTÂNCIA - SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única - o paciente, personificado pelo impetrante -, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - IRREGULARIDADE - CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo Órgão judicante. COMPETÊNCIA - AFERIÇÃO - JUÍZO. A competência há de ser aferida considerado o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA - REPERCUSSÃO - AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a formalização do flagrante não repercute na validade da ação penal. TRÁFICO DE DROGAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.

(HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)"

Por outro lado, os testemunhos dos policiais reforçam o reconhecimento da causa de aumento da pena contida no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, considerando que a ação delituosa do tráfico ilícito de drogas foi praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino (laudo de fls. 155/159), beneficentes e de trabalho coletivo, situada próxima da residência do acusado, de modo que, in casu, a incidência objetiva da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, é imperativa, a qual tem natureza jurídica de perigo abstrato (perigo presumido na lei, jure et jure, pela simples prática da conduta), independentemente da necessidade de restar provada, caso a caso, a efetiva facilitação no aliciamento de pessoas ao comércio e consumo de drogas (AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

No mais, o crime foi praticado em concurso com um adolescente, donde a incidência do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Dispõe o art. 33, §4º, da Lei

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique

às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre a figura do tráfico privilegiado, cumpre firmar, desde já, algumas premissas, colhidas da pacífica jurisprudência dos tribunais superiores:

(i) a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes (HC 510077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no REsp 1449194/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/09/2017, DJe 04/10/2017);

(ii) a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa (AgRg no HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no REsp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, j.m 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

(iii) é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (EResp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).

(iv) é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa (AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/06/2019, DJe 02/08/2019; AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.14/05/2019, DJe 24/05/2019);

(v) diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito (HC 477280/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; HC 458735/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 23/10/2018);

(vi) as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Repercussão Geral Tema 712). Assim, a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem (AgRg no HC 497047/SP, Rel. Min. Rogério SCchietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/05/2019, DJe 25/06/2019; HC 472052/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

(vii) a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF (HC 510248/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, DJe 13/06/2019; HC 491328/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.18/06/2019, DJe 01/07/2019);

(viii) reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistirá óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (HC 482234/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.em 06/06/2019, DJe 14/06/2019; HC 482626/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/03/2019, DJe 09/04/2019); e

(ix) o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600; AgRg no HC 485746/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019, DJe 17/06/2019; AgRg no HC 485237/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

No presente caso, nota-se a diversidade de entorpecentes apreendidos e, embora a parte ré seja tecnicamente primária, responde por outro processo análogo a este em julgamento, razão pela qual não se aplica o parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

De outro lado, a denúncia não vinga quanto o crime previsto no art.35, 'caput', da Lei de Drogas, posto que a prova colhida não é segura quanto a estabilidade daquelas ações conjuntas, salientando-se que 'O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência' (STF, HC nº 124.164/AC, rel. Min. TEORI ZAVASCKI; HC nº 121.188, rel. Min. DIAS TOFFOLI, etc.).

No mesmo sentido: 'Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula "reiteradamente ou não", poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art.288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar' (VICENTE GRECO FILHO, *Tóxicos: prevenção-repressão*, 14. ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p.209).

De tal sorte não há se falar em crime autônomo previsto no art.35, da Lei de Drogas.

Não incidem quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Responsabilidade Penal

Tudo bem examinado e ponderado, deve ser observado, ainda nesta sede, que nada alegou a defesa que permitisse afastar a antijuridicidade da conduta delitiva imputada à parte ré, a qual, aliás, agiu com entendimento, autodeterminação e ciência da ilicitude do fato praticado, quando era certamente de se lhe exigir a adoção de conduta diversa.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o Sr. Tháyra Gabriela Alves Silva praticou o delito de Tráfico de Drogas, devendo ser responsabilizado penalmente pela suas condutas.

III - FIXAÇÃO DA PENA

Dosimetria da Pena do Crime de Tráfico de Drogas praticado pela Sra. Tháyra Gabriela Alves Silva.

Em atenção ao Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, inc. XLVI, da CF/88) e ao Sistema Trifásico (art. 68 do CP), passo à dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei 11.343/06), deve ser observado que embora a natureza da droga apreendida seja altamente deletéria, a quantidade, ainda que relevante, é pequena, razão pela qual não há que se valorar esta circunstância judicial negativamente. No mais, tem-se que:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), tem-se que:

i) Na análise da culpabilidade, deve-se examinar, na lição de Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 788), "(...) a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu". Nada há nos autos que permita concluir por um grau diferenciado de censura da parte ré. Em outras palavras, o grau de censura necessário já é alcançado pelo mínimo da pena aplicada. Assim, a culpabilidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

ii) Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Antes, porém, de proceder a este exame, faz-se oportuno estabelecer alguns parâmetros - à luz da doutrina e da jurisprudência dominantes -, a serem observados.

Segundo Masson, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 416), para a caracterização dos maus antecedentes, "basta a existência de uma condenação penal definitiva", sendo que o "trânsito em julgado da condenação pode ser anterior ou posterior à prática do novo delito". Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado.

Nesta ordem de ideias, pode ocorrer de a parte ré possuir uma ou mais condenações definitivas por fatos praticados antes do que está sendo atualmente julgado.

Cumpra, portanto, estabelecer uma casuística a este respeito.

Em havendo uma única condenação por infração penal anterior, registrada no histórico criminal da parte ré, devem-se distinguir ao menos duas situações: (i) se o trânsito em julgado da condenação pelo fato pretérito for posterior ao fato em julgamento, então estar-se-á diante de um mau antecedente; ou (ii) se tanto o fato pretérito, quanto o trânsito em julgado da condenação a ele relativa, forem anteriores ao fato em julgamento, então estar-se-á diante da reincidência em sentido técnico (art. 63 do CP), salvo se houver transcorrido o prazo depurador (art. 64, inc. I, do CP), hipótese em que a condenação definitiva anterior será valorada como antecedente criminal, observado o sistema da perpetuidade, abaixo examinado.

Em havendo duas ou mais condenações por infrações penais anteriores, registradas no histórico criminal da parte ré, pode ocorrer de: (i) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado (a) após o trânsito em julgado de uma condenação por delito anterior, caso em que essa será valorada como reincidência; e (b) após a prática de outro delito, cujo trânsito em julgado sobreveio antes do julgamento atual, caso em que essa será valorada como mau antecedente; ou (ii) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado após o trânsito em julgado de duas ou mais condenações por delitos anteriores, caso em que uma poderá ser considerada como reincidência e a outra (ou mais) como mau antecedente, observado o entendimento consagrado na Súmula 241 do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial").

Aqui, cabe observar que, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo 1077, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Um resumo do quanto exposto nos é oferecido por Masson (idem, p. 444): "(...) se o réu possui mais de uma condenação definitiva, uma pode ser utilizada como mau antecedente e a outra como agravante genérica (reincidência, não se falando em bis in idem. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, o magistrado deve utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, se for o caso, e as demais como maus antecedentes."

Sobre o momento da condenação penal definitiva utilizada como mau antecedente, vale observar que a ela não se aplica o período depurador de que trata o art. 64, I, do CP, conforme decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, RE 593.818, Tema 150. Em outras palavras, o sistema penal adota a regra da perpetuidade em matéria de antecedentes (nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: 5ª Turma, AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 15/09/2020, DJe.

21/09/2020; e 6ª Turma, AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). Portanto, é possível considerar qualquer condenação anterior (desde que já transitada em julgado e relativa a fato praticado antes

daquele atualmente em julgamento), ressalvadas aquelas por atos infracionais pretéritos, pois que não configuram "crime" em sentido estrito (STJ, 5ª Turma, HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe. 12/02/2021; e STJ, 6ª Turma, REsp 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/03/2018, DJe. 14/03/2018).

Por fim, conforme pacífico entendimento do STJ, "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula 636 do STJ), o que, contudo, não afasta a possibilidade de serem eles comprovados por outros meios (STF, 1ª Turma, HC 162.548, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/06/2020, DJe. 03/07/2020; e STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2018, DJe. 24/08/2018). Veda-se, todavia, por força do Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF/88), a utilização de "inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ).

Postas estas premissas, ao analisar a Folha de Antecedentes Criminais (fl. 76) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fl. 76/77) da parte ré, não se constata nenhuma condenação definitiva por infração praticada antes desta em julgamento. Assim, os antecedentes devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

iii) Na análise da conduta social, consoante a já clássica lição de Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 791), deve-se examinar "o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc." Assim, não se pode confundir os antecedentes sociais da parte ré com os seus antecedentes criminais, de modo que se acabe valorando esses últimos nesta sede (STJ, 5ª Turma, HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2018, DJe. 19/12/2018; e STJ, 6ª Turma, REsp 1.760.972/MG, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/2018, DJe. 04/12/2018)

Nada há nos autos que desabone a conduta social da parte ré. Assim, sua conduta social deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

iv) Na análise da personalidade do agente, "entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo" (idem, p. 790), deve-se examinar a sua índole e caráter. Este exame deve-se pautar em elementos concretos, sendo insuficiente, para fins de justificação de eventual valoração negativa, a simples menção a uma "personalidade criminosa" (STJ, 6ª Turma, HC 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015, DJe. 11/12/2015)

Não há nos autos elementos concretos que permitam aferir conclusivamente a personalidade da parte ré. Assim, sua personalidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

v) Na análise dos motivos do crime, entendidos como "a fonte propulsora da vontade criminosa" (idem, p. 791), deve-se examinar a natureza e a qualidade dos motivos, ou, na lição de Hungria, citada por Bittencourt (idem, ibidem), se são morais/imorais ou sociais/antissociais.

Os motivos que levaram a parte ré a cometer o delito não fogem daquilo que é comum nos crimes deste jaez. Assim, os motivos devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

vi) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt (idem, ibidem), as circunstâncias "defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objetos, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes", devendo-se cuidar que "determinadas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime ou, de alguma forma, são valoradas em outros dispositivos, ou até mesmo como elementares do crime", hipóteses em que deverão ser examinadas em outro momento. As circunstâncias em que se deu o crime já estão abrangidas pelo tipo penal. Assim, as circunstâncias do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

vii) Na análise das consequências do crime, deve-se ter em vista que essas não se confundem com o resultado natural ou jurídico do crime. Mais uma vez, na lição de Bittencourt (idem, p. 792), cabe "analisar a maior ou menor danosidade decorrente da

ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime." Não se constata que o crime tenha gerado danosidade que já não esteja abrangida pelo tipo, nem há notícia de alarma social. Assim, as consequências do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

viii) O crime em questão é classificado doutrinariamente como delito vago, isto é, conquanto o Estado seja considerado uma vítima indireta, não há nenhuma vítima direta definida, razão pela qual não se cogita do comportamento da vítima para a produção do resultado delitivo.

Para a valoração das circunstâncias judiciais negativas, utilizo a fração de 1/8, filiando-me ao recente precedente do STJ:

"4. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

5. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

(AgRg nos EDcl no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)"

Não havendo circunstâncias judiciais negativas, a pena-base fica fixada no mínimo legal, isto é 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que:

i) Não incidem quaisquer circunstâncias agravantes.

ii) Não incidem quaisquer circunstâncias atenuantes.

Para a valoração das agravantes e das atenuantes, valho-me da fração de 1/6 (STF - HC: 69392 SP, Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/1992, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 12-03-1993 PP-03560 EMENT VOL-01695-03 PP-00610).

Não havendo quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, a pena-intermediária fica fixada no mesmo patamar da pena-base, isto é 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, tem-se que:

i) Incide as causas de aumento do art. 40, III e VI, da Lei de Drogas.

ii) Não incidem quaisquer causas de diminuição da pena.

Não incidentes quaisquer causas de diminuição, a pena é aumentada em 2/3, pelas hipóteses dos arts. 40, III e VI, da Lei de Drogas resultando em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Valor do Dia-Multa

Fixo o valor da dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), uma vez que não há nos autos dados suficientes à análise exauriente da situação econômica da parte ré (art. 60, caput, do CP).

Detração

Deixo de efetuar a detração (art. 42 do CP), como manda o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes informações suficientes sobre imposição e cumprimento de penas privativas de liberdade por outros crimes (art. 111 da LEP).

Regime Inicial de Cumprimento

Dispõe o art. 33 do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento

adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

- a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
- b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
- c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir da aferição de quatro critérios: tipo de pena prevista para o tipo legal (reclusão ou detenção), quantidade de pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais (art. 33, §§2º e 3º, do CPP), sendo certo que a imposição de regime mais severo do que o permitido pela pena aplicada exige motivação idônea (Súmula 719-STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea"), exigência essa não satisfeita pela mera menção à gravidade em abstrato do crime (Súmula 718-STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada").

No presente caso, tem-se que:

- i) a pena ficou definitivamente fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão.
- ii) a parte ré é primária; e
- iii) as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Portanto, entende-se como correto o estabelecimento do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.

Observe-se que desde há muito que se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos (STF, Plenário, HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/06/2012).

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos

Dispõe o art. 44 do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz

da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos depende do preenchimento de requisitos objetivos (natureza do crime e quantidade de pena aplicada) e subjetivos (não ser reincidente em crime doloso, observada a exceção da recomendação social da medida, e ser suficiente a substituição).

No presente caso, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Neste ponto, aliás, cumpre rememorar que, reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexiste óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (HC 482234/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/06/2019, DJe 14/06/2019; AgRg no REsp 1777922/SP, Rel. Min.

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Suspensão Condicional da Pena (Sursi)

Dispõe o art. 77 do CP:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena depende do preenchimento de requisitos objetivos (natureza e quantidade da pena privativa de liberdade e sua não substituição por restritiva de direitos) e subjetivos (não ser reincidente em crime doloso e parcela das circunstâncias judiciais favoráveis).

No presente caso, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 2 (dois) anos.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade da concessão da suspensão condicional da pena.

IV- DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR a Sra. Tháyra Gabriela Alves Silva, qualificada à fl. 74, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa, com o dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser inicialmente cumprida em regime fechado. Isso por considerar a parte ré como incurso no art. 33, caput, c.c o artigo 40, incisos III e IV da Lei 11.343/06 e ABSOLVER a Sra. Tháyra Gabrieal Alves Silva, da prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII (não existe prova suficiente para a condenação).

V - COMUNICAÇÕES FINAIS

Em atenção ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, observe-se que a parte ré respondeu a este processo presa, nada tendo sobrevivendo no curso do processo a alterar o juízo sobre a necessidade da imposição de sua prisão preventiva. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado. Recomende-se, portanto, o réu preso no estabelecimento em que se encontra.

Condene a parte ré ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/2003). Neste ponto, observe que não há lacuna no CPP,

a atrair a incidência do CPC/15, notadamente dos dispositivos que ali tratam sobre a gratuidade de justiça. Quisesse o legislador isentar o acusado pobre das custas nos crimes de ação penal pública, teria o feito, como de fato o fez no art. 806, §1º, do CPP. Nem se diga que o art. 806, §1º aplica-se à hipótese, pois, como se sabe, o parágrafo excepciona a regra do caput (art. 11, inc. III, alínea "c", da LC 95/98).

Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita, em se tratando de ação penal pública, cabe ao Juízo da Execução Penal (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; e AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 04/02/2020, DJe 27/02/2020), sendo certo que a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça não exclui a possibilidade de condenação do acusado ao pagamento de custas processuais, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; e AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 11/04/2019, DJe 30/04/2019).

Determino o perdimento dos bens (rolo de plástico filme, etiqueta de QR Code e máquina de tíquete - Mercado Pago - art. 91, inc. II, do CP) e dos numerários apreendidos em favor da União (art. 63, inc. I e art. 62-A, §3º, da Lei 11.343/06). Em relação aos aparelhos celulares apreendidos, por não haver prova de que tenham sido utilizados para a prática do crime ou mesmo terem sido produtos dele, determino a restituição dos mesmos, a quem de direito, expedindo-se o necessário. Proceda-se em relação às drogas na forma do art. 72 da Lei 11.343/06, acaso não se tenha procedido na forma dos arts. 50 e 50-A do mesmo diploma legal.

Transitado em julgado: (i) proceda-se à atualização do valor da multa, intimando-se o réu para pagamento em 10 dias, nos termos dos arts. 49, §2º, 50 e 51 do CP e 164 da LEP; (ii) oficie-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III, da CF/88; (iii) oficie-se o IIRGD.

Expeça-se Certidão de Honorários Advocatícios, nos termos do Convênio DPE/OAB, se for o caso.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Ilha Solteira, 21 de Julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA